

1500081-81.2022.8.26.0557

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ANDERSON VALENTE

Comarca: Guaíra

Foro: Foro de Guaíra

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 12/05/2022

... é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Guaíra

Foro de Guaíra

1ª Vara

Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500081-81.2022.8.26.0557 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500081-81.2022.8.26.0557

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ISRAEL HENRIQUE DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. ISRAEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado a fls. 17, foi denunciado e viu-se processado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 28 de

janeiro de 2022, por volta das 21h, na Avenida 25 nº 149, Bairro Paranoá, nesta cidade e Comarca, teria trazido consigo, com finalidade de traficância e entrega ao consumo de terceiros, vinte e seis porções de maconha, com peso bruto de 54,590 g de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

É da denúncia que “policiais militares realizavam patrulhamento na Avenida 25 com a Rua 44-A, local já conhecido pelo tráfico de drogas, quando avistaram ISRAEL sentado em uma cadeira.

Deliberando pela abordagem, os policiais se aproximaram, momento em que o denunciado tentou correr, sendo detido poucos metros depois.

Em revista pessoal, foi encontrada no bolso de sua bermuda a quantia de cento e vinte e seis reais em cédulas diversas. Na cadeira onde ISRAEL estava sentado, foi localizada uma sacola com vinte e seis porções de maconha.”.

A denúncia de fls. 96/97 foi recebida em 25 de fevereiro de 2022 (fls. 99), sendo o Réu citado (fls. 109), apresentando defesa preliminar em fls. 114/116, rejeitada em fls. 124/126. Durante a instrução foi colhida prova oral e interrogado o Réu (fls. 154).

Em memoriais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia (fls. 152/153).

A douta Defesa, por seu turno, requereu a improcedência da ação, alegando a inexistência de provas que indicassem ser o Réu narcotraficante. Dessa forma, requereu a absolvição do Acusado e, subsidiariamente, a fixação da pena no menor patamar, com regime mais brando para início do cumprimento da pena (fls. 156/158).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A ação penal é procedente.

A materialidade delitiva está estampada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/05), boletim de ocorrência de fls. 06/07, auto de exibição e apreensão de fls. 08, auto de constatação de fls. 10/12, comprovante de depósito de fls. 91, pelo laudo de exame químico-toxicológico a fls. 107/108, além da prova oral colhida durante a persecução.

A autoria é certa contra o Réu que na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 04), ao passo que em Juízo negou o teor da acusação, sustentando que estava na casa de sua esposa, sentado na cadeira na esquina da residência, debaixo de um toldo, quando policiais chegaram e realizaram sua abordagem, mas nada localizando, de forma que passaram a procurar algo no fim da rua, retornando e, como havia saído da prisão há pouco tempo, foi algemado, nada sendo dito pelos militares. Alega, ainda, que não deixaram que prestasse depoimento na delegacia, foi coagido a assinar os documentos do auto de prisão e somente soube que estava preso por tráfico quando citado. Ademais, disse que o local é ponto de venda de drogas, mas não tinha relação com isso. Por fim, não é usuário de drogas e trabalhava, sendo o dinheiro apreendido, mesmo em notas miúdas, fruto de seu labor.

Sua versão não convence e restou isolada nos autos, sendo que, caso verdadeira, faria prova de suas alegações, em especial ouvindo sua esposa, ônus que lhe competia, com fundamento no artigo 156 do Código de Processo Penal.

De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime assemelhado ao hediondo tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada,

demonstrando que o Réu nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois o Réu “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

No mais, as testemunhas de acusação demonstraram coesão no depoimento, isolando, assim, a versão do Réu.

De fato, José Roberto, ouvido em Juízo, destacou que estavam em patrulhamento em conhecido ponto de venda de drogas quando encontraram o Réu sentado em uma cadeira de plástico debaixo de uma cobertura ali realizada, mas ele não percebeu a aproximação, o que permitiu que fosse prontamente abordado e, ao ver a situação, tentou levantar e correr, mas foi detido, encontrado o entorpecente, que estava embaixo da perna do Acusado, além de dinheiro. No mais, o Réu não aparentava estar sob efeito de drogas. Em linhas gerais, o mesmo teor do depoimento do policial Almeaní, que ainda relatou que apesar de não conhecer o Acusado, por ser novo na cidade, ele é conhecido dos policiais mais antigos, inclusive por tráfico, além de destacar que no momento da abordagem a esposa do Réu chegou e passou a discutir com o Acusado dizendo que sempre falava para ele sair dessa vida.

A conduta do Acusado, pois, indica que no dia, horário e local apontados na denúncia, trazia consigo substância entorpecente para fins de traficância. A isso se chega com a prova coligida aos autos, notadamente a considerável quantidade de entorpecente apreendida, o dinheiro sem origem comprovada, a tentativa de fuga do Réu ao avistar a viatura, estar em conhecido ponto de venda de drogas, inclusive em uma cobertura ali colocada, assim como o fato de declarar sequer ser usuário de entorpecentes. Tais condutas apontam que o Réu utilizava o entorpecente apreendido consigo para fins de mercantilização, consoante se extrai do artigo 28, parágrafo 2º, da Lei 11.343, de 23.08.2006.

Nem se olvide pelo fato de a acusação se embasar somente no depoimento prestado por policiais, que é válido e está em consonância com as demais provas, sem existência de qualquer indicativo de sua imprestabilidade, motivo por que não podem ser descartados, notadamente porque o Réu não ofertou qualquer resistência ao depoimento deles.

A condição funcional não os torna suspeitos, valendo, outrossim, o princípio de presunção de legitimidade dos atos administrativos praticados. Nesse diapasão, “Com relação aos depoimentos de policiais, os entendimentos jurisprudenciais têm convergido na direção de que são eles válidos e aptos ao suporte de uma condenação, pois aqueles agentes da autoridade prestam os seus esclarecimentos sob o compromisso da verdade como qualquer testemunha e as suas narrativas devem ser entendidas como verdadeiras até a produção de provas em contrário, com demonstração da falácia, recaindo o ônus da produção destas na esfera da defesa, situação que inocorreu nos autos.

Pequenas divergências encontradas no cotejo dos depoimentos prestados pelos policiais, sem atingirem o âmago da questão, devem ser desprezadas, posto que podem ser produto do posicionamento dos mesmos quando da diligência efetuada e das tarefas de cada um deles naquele momento, além do entrelaçamento de situações diante do elevado número de ocorrências que tais policiais atendem no dia a dia, sem o comprometimento daquilo que narraram” (TJSP, Ap. 990.08.168537-0, 10ª C.D.Crim., Rel. Des. Otávio Henrique, j. 16.04.2009).

Assim, tem-se o depoimento isolado do Réu dado em Juízo que, por motivos óbvios, possui intenção de se isentar das penas da narcotraficância e, de outro lado, o depoimento uníssono dos policiais militares, agentes públicos que contaram com detalhes a prisão do Réu, nada sendo levantado e muito menos comprovado contra

eles, de forma que viesse a colocar em xeque seus depoimentos.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do acusado ou extingam a punibilidade. Sendo assim, reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar a pena.

O Acusado ostenta péssimos antecedentes, demonstrando, assim, ter personalidade persistente na prática de condutas antissociais. Contudo, na primeira fase da dosimetria, fixo a pena-base no mínimo legal para não provocar um bis in idem com a agravante da reincidência. Sendo assim, apreciando os parâmetros legais ditados pelo artigo 59 do Código Penal, onde não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar, a pena-base ser fixada no mínimo legal, ou seja, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase aumento sua pena em 1/2 (metade) em razão da tripla reincidência em crimes dolosos (cf. fls. 33, autos nº 0000072-72.2017.8.26.0557; fls. 33/34, processo nº 0000201-77.2017.8.26.0557; fls. 34/35, processo nº 0001668-65.2017.8.26.0210), atingindo o patamar de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

O Acusado não faz jus à causa de diminuição da pena prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas, uma vez que a forma como se desenhou os fatos, sendo ele, triplamente reincidente, conhecido pela traficância, vem a demonstrar que se dedica, indubitavelmente, à atividade criminosa do tráfico de drogas, tanto que não demonstrou possuir ocupação lícita.

Nesse diapasão: "Para redução da pena, essencial que o réu seja 'primário', apresente 'bons antecedentes', comprove que 'não se dedique às atividades criminosas', assim como, 'nem integre organização criminosa'.

Evidente que essa causa de redução da pena está reservada àquele que age por um impulso, um desvio, em situação isolada no tráfico de drogas. E mais, os parâmetros para a graduação da redução (1/6 a 2/3) devem ser objetivos e extraídos das diversas circunstâncias que envolvam o caso concreto, podendo variar dentro do seu campo de incidência. Essa causa de redução da pena deve incidir na excepcionalidade, em situações específicas, próprias, quando patente que o tráfico apurado cuidou-se apenas de um desvio na vida do réu, e não de uma contumácia, estilo, repetição de fato análogo, de uma rotina de proceder.

Ao julgador compete a análise do impulso, do fator determinante da conduta objetivamente tratada, que lhe permita concluir tratar-se mesmo de caso de um criminoso meramente ocasional, ou mesmo, se vem tomando aquela conduta como estilo de vida, para que possa, não apenas determinar a gradação da redução da pena, como até mesmo o total afastamento da causa de redução" (TJSP, Ap. 0003548-97.2014.8.26.0210, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Luiz Antonio Cardoso, j. 30.07.2019).

O regime de cumprimento de pena adequado, por se tratar de crime equiparado ao hediondo, é o inicial fechado. Nesse panorama: "O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto acerto, não só por previsão legal artigo 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação dada pela Lei nº 11.464/07 como, também, pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e social. Tanto é que o delito é equiparado aos hediondos.

O crime de tráfico de entorpecentes é equiparado aos delitos hediondos, portanto os mais graves dentre os elencados no Código Penal e em Leis Especiais.

Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.

Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas, considerado o § 4º, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem dúvida, crime grave.

Mas há os considerados hediondos.

Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo, absolutamente intolerável.

Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo, como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?

O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a cocaína e o 'crack', por exemplo, além de causarem dependência, destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações, e o que é pior: com mínimas chances de recuperação. Bem por isso que se trata de crime hediondo.

A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.

O legislador, com a edição da Lei nº 11.343/06, passou a punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser preservados.

Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro e patrimônio amealhados de forma criminoso, poderão deixar o País e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.

Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que menos os preocupa" (TJSP, Ap. 0000555-39.2016.8.26.0557, 15ª C.D.Públ., Rel. Des. Poças Leitão, j. 01.02.2018).

Por outro lado, é vedada a concessão de sursis ou substituição por pena restritiva de direitos, pela ausência dos requisitos subjetivo e objetivo. Ressalto, quanto tal aspecto que, não obstante a decisão tomada no HC 97.256/RS, do STF, que não possui cunho vinculante, com a devida vênia, não se verifica compatibilidade lógica da pena restritiva com a natureza da infração, sendo que deveria a defesa fazer prova de que o Acusado possui condições da substituição da pena corporal, o que não é afastado nem mesmo diante da Resolução nº 5/2012 do Senado, não havendo que se falar em violação ao princípio da individualização da pena, porquanto esta deve se dar respeitando parâmetros preestabelecidos pela lei, notadamente porque o artigo 5º, inciso XLIII, da CF/88 determinou regime mais rigoroso na reprimenda de crimes hediondos e equiparados.

Relevo, ainda, que a disposição do artigo 44 do Código Penal, que trata da conversão de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, não é de aplicação automática, pois elenca os requisitos legais para tanto. Ali, em seu inciso III, estabelece que somente é aplicável a comutação quando a conduta social do réu, além dos motivos e circunstâncias do delito, forem favoráveis. A simples prática do narcotráfico, este o flagelo de nossa sociedade, indica o sujeito ativo do crime como pessoa portadora de péssima conduta social, sendo que os motivos e circunstâncias do crime são, evidentemente, desfavoráveis. Para isso, basta se ter contato com um usuário de entorpecente para se verificar a miséria que se tornou sua existência (e de sua família), tão-somente pelo consumo daquilo que é oferecido pelo traficante (ainda que seja um "pequeno" traficante).

Para o crime de narcotráfico, circunstâncias como primariedade, bons antecedentes ou emprego lícito (sendo que o Réu não é possuidor de nenhum destes predicados) servem para fixar a pena aplicada, bem como, quando o caso, o critério redutor. Contudo, não viabiliza a conversão em pena restritiva ou mesmo a fixação em regime que não o fechado, em vista dos diplomas legais acima citados, pois insuficiente à repressão e prevenção desta infração equiparada à crime delito hediondo. Nesse sentido, lapidar excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, verbis: "Ressalta-se que a decisão apresentada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC nº 111.840/ES, em 27 de junho de 2012, reconhecendo e declarando

incidentalmente a inconstitucionalidade do artigo 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90 tem seus efeitos 'restritos ao processo e às partes litigantes', não possuindo efeito 'erga omnes', até porque, não afastada pela Suprema Corte a natureza hedionda do delito de tráfico, justificando a imposição do regime mais gravoso, em respeito aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da individualização da pena. Nesse mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, possibilitando a imposição de regime fechado para o crime de tráfico de entorpecente: HABEAS CORPUS nº 189.960/SC, Quinta Turma, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.08.2012; HABEAS CORPUS 216.265/SP. Rel. Min. Og Fernandes, DJe 02.06.2012; HABEAS CORPUS 199.619/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 27.08.2012; e HABEAS CORPUS nº 225.568/ES, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe. 27.08.2012.

Não há que se falar em conversão da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, havendo a necessidade de pronunciar algumas considerações. Com efeito, o Senado, na forma do artigo 52, inciso X da Constituição Federal e com olhos voltados para o julgamento do HC nº 97.256/RS, pelo Supremo Tribunal Federal, editou a Resolução nº 05/2012, cujo teor é a suspensão da parte que obstaculizava a conversão da pena privativa de liberdade em pena alternativa, inserida no parágrafo 4º, do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.

No entanto, com a devida vênia, o traficante, seja de pequeno, de médio ou de grande porte, não tem mérito para inicialmente cumprir a pena cominada de outra forma que não encarcerado.

Em vista o postulado implícito da proporcionalidade (HUMBERTO ÁVILA, Teoria dos Princípios, Ed. Malheiros), que é uma espécie de norma jurídica derivada do devido, justo e adequado processo legal (FAIR TRAIL), não se mostra razoável que o traficante, condenado por delito equiparado a hediondo (artigo 5º, inciso XLIII da Constituição Federal) venha a receber tratamento similar ao agente que perpetra um delito de menor potencial ofensivo.

Nesse contexto, pondera-se: de onde viria o numerário para o traficante cumprir a prestação pecuniária? E mais: onde o traficante, disseminador de vício, cumpriria prestação de serviços à comunidade ou entidade pública? Nas escolas? Nas creches? Nos orfanatos? Nos abrigos? Nos hospitais?

Em suma, não se mostra adequada a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito em casos de tráfico de entorpecente, uma vez que tal medida atenta contra a efetividade do processo penal na aplicação do justo concreto, atingindo frontalmente o caráter retributivo da reprimenda e a dimensão material ou substancial do 'DUE PROCESS OF LAW'.

Além disso, é válido ressaltar que os recentes arestos do Colendo Superior Tribunal de Justiça indicam que não há ilegalidade na negativa de permuta, quando fundada na multiplicidade e na natureza lesiva das drogas apreendidas, isso porque a conversão da sanção reclusiva não seria suficiente para a prevenção e a repressão do delito denunciado (HC 204115 / MG - Ministro JORGE MUSSI - QUINTA TURMA - DJe 15/02/2012). E, na espécie, como foram apreendidas porções consideráveis de 'maconha', a aplicação de pena alternativa encontra óbice na exegese do artigo 44, inciso III, do Código Penal, sendo insuficiente como resposta à culpabilidade do agente, aos motivos e às consequências do exercício da atividade ilícita" (TJSP, Ap. 0005407-56.2011.8.26.0210, 4ª C.D.Crim., Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 18.12.2012).

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, com redação dada pela Lei 11.719, de 20.06.2008, porquanto o crime apurado é classificado como vago, assim entendido aquele que tem por sujeito passivo a sociedade, destacando, outrossim, que não se comprovou qualquer dano causado em sujeitos passivos secundários (pessoa submetida aos riscos da lesão).

À derradeira, tendo em vista que o Acusado foi condenado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, sendo com ele localizado quantia em dinheiro sem comprovação de regularidade em seu recebimento, evidenciando-se ser o numerário fruto da venda de drogas ilícitas, com fulcro no artigo 63, caput, do aludido

diploma legal, decreto a perda dos valores apreendidos com o Réu, depositados em Juízo (fls. 91), que deverão ser encaminhados em favor da União, com o trânsito em julgado desta sentença (artigo 63, parágrafo 1º).

III. Isto posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e, em consequência, CONDENO o Réu ISRAEL HENRIQUE DA SILVA, qualificado nos autos, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa, em seu piso legal, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, em regime inicial fechado, vedadas a substituição por pena restritiva de direitos ou a concessão de sursis. No mais, decreto a perda do dinheiro apreendido com ele, depositado a fls. 91, em favor da União.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal), bem como encaminhe-se o numerário apreendido, depositado a fls. 91, em benefício da União.

Diante da pena aplicada, em regime inicial fechado em razão da equiparação à hediondez do crime, o Réu, descontente com a decisão, deverá aguardar o julgamento do recurso preso, motivo por que mantenho sua prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal, nada justificando que preso em flagrante fosse posto em liberdade depois de condenado por crime equiparado ao hediondo.

São devidas custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 12 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA